

1500378-14.2021.8.26.0593

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NAIARA SOUZA LIMA e outro

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ROBSON RODRIGUES BARBOSA e NAIARA SOUZA LIMA como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500378-14.2021.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500378-14.2021.8.26.0593

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NAIARA SOUZA LIMA e outro

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ROBSON RODRIGUES BARBOSA e NAIARA SOUZA LIMA como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 e com artigo 29 do Código Penal. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não apurada do mês de agosto de 2021, nesta Comarca, NAIARA SOUZA LIMA, qualificada à fls. 05, e ROBSON RODRIGUES BARBOSA, qualificado às fls. 72, previamente ajustados e com cooperação de esforços, adquiriram e, no dia 21 de agosto de 2021, por volta de 13h:40min, na Rodovia SP-294, Km 465, Penitenciária de Marília, nesta cidade de Marília, traziam consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 33,68g (trinta e três gramas e

sessenta e oito centigramas) de cocaína e 67,29g (sessenta e sete gramas e vinte e nove centigramas) de Cannabis Sativa L (maconha), conforme auto de apreensão exibição de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 16/18 e laudo químicotóxicológico de fls. 67/71, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, ROBSON RODRIGUES BARBOSA, que cumpre pena na Penitenciária de Marília (fls. 73 e 81), determinou e instigou à companheira NAIARA SOUZA LIMA, cadastrada como visitante dele naquele estabelecimento, que adquirisse cocaína e maconha e levasse os entorpecentes assim que fosse visita-lo.

Dando cumprimento ao pactuado com o companheiro, NAIARA adquiriu as drogas especificadas no preâmbulo e, no dia 21 de agosto de 2021, as introduziu na genitália e se dirigiu à Penitenciária de Marília, a pretexto de visitar ROBSON, a quem os entregaria, para que ele realizasse a difusão dos tóxicos no ambiente carcerário.

Todavia, seguindo os protocolos de segurança, NAIARA foi submetida ao "scanner corporal", ocasião em que se identificou na região pélvica da indiciada sinais de volume suspeito (fls. 10).

Ao ser informada que seria conduzida a um hospital para averiguação, NAIARA admitiu trazer entorpecentes consigo, retirando-os da vagina e entregando à agente penitenciária.

As circunstâncias do flagrante, a diversidade e grande quantidade (para o local dos fatos) de entorpecentes, evidenciam a intenção de tráfico de drogas por ambos os denunciados.

Auto de prisão em flagrante fls. 01/02.

Boletim de Ocorrência fls. 07/09.

Auto de exibição e apreensão fls. 11/12.

Laudo de Constatação fls. 16/18.

Suspensa a audiência de Custódia, foi concedida a liberdade provisória da ré fls. 52/54.

Dado o cumprimento ao Alvará de soltura em favor da ré às fls. 59/60.

Laudo pericial definitivo de entorpecentes fls. 67/71.

Notificada a ré fls. 120/121, a mesma apresentou resposta à acusação às fls. 123/124

Notificado o réu fls. 139/140, o mesmo apresentou resposta à acusação às fls. 144/146.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento, foi recebida a denúncia em 25 de agosto de 2022 e ato contínuo, foi colhido o depoimento da testemunha Márcio Diovani da Rocha, bem como os réus Naiara Souza Lima e Robson Rodrigues Barbosa, foram interrogados, pelo sistema de gravação audiovisual. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça por ele foi dito que desistia da oitiva da testemunha Alessandra dos Santos Martins, o que foi homologado pelo MM. Juiz.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu que a presente ação penal seja julgada procedente para condenar ROBSON RODRIGUES BARBOSA e NAIARA SOUZA LIMA como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº

11.343/2006 e com artigo 29 do Código Penal. No que se refere à dosimetria da pena do denunciado ROBSON RODRIGUES BARBOSA, na primeira fase a pena deve ser fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do acusado. Na segunda fase a pena deve sofrer novo aumento em razão da reincidência do réu. Na terceira fase a pena deverá sofrer aumento de um sexto a dois terços, tendo em vista que a infração foi cometida nas dependências de estabelecimento prisional. O regime de pena, em face das observações acima, deve ser o fechado. Em relação a dosimetria da pena da denunciada NAIARA SOUZA LIMA, na primeira fase observamos que a autora não possui antecedentes criminais. Na segunda fase não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase a pena deverá sofrer aumento de um sexto a dois terços, tendo em vista que a infração foi cometida nas dependências de estabelecimento prisional. O regime de pena, em face das observações acima, deve ser o fechado.

O Dr. Defensor Público, em alegações finais em audiência, requereu a absolvição da denunciada Naiara em razão da atipicidade da conduta. Se entende como plenamente

caracterizado, no caso em apreço, o instituto do crime impossível, devendo ser absolvida a ré, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, tudo por ser medida de Justiça. Impõe-se a absolvição do denunciado Robson em razão da atipicidade da conduta. DA PENA E REGIME: Com relação à denunciada Naiara, caso a absolvição não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer a fixação de pena em patamar mínimo, em regime brando, considerando a primariedade da ré, reconhecendo-se, em relação ao tráfico, no patamar máximo, o privilégio descrito no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 ou, subsidiariamente, a diminuição em razão da tentativa. Por fim, aguardo a fixação de regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Com relação ao denunciado Robson, caso a absolvição não seja o entendimento de Vossa Excelência, com relação a dosimetria da pena, requer a fixação da pena nos patamares mínimos, aplicando-se a diminuição em razão da tentativa e desconsiderando a majorante prevista no inciso III, do art. 40 da Lei 11.343/06. Com relação ao regime de pena, pugna pela substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de eventual condenação.

É O RELATO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação passo ao julgamento do mérito.

A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência nº 6363/2021 de fls. 07/09, do auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo químico toxicológico de fls. 67/71, bem como por meio da prova oral produzida nos autos sob o crivo do contraditório.

Passo à análise da autoria.

Eis a prova oral colhida.

Em solo policial, a testemunha Alessandra dos Santos Martins, relatou que na data de 21/08/2021, por volta das 13:40 horas, estava acompanhando a entrada de visitas junto ao equipamento "scanner corporal" e no momento em que a visitante de nome NAIARA SOUZA LIMA foi submetida a exame e verificou que havia um objeto estranho na região pélvica dela (NAIARA). Alega a depoente que indagou NAIARA sobre tal objeto, ocasião em que ela informou que não estar com objeto algum. Informa a depoente que diante disso, informou o funcionário de nome MÁRCIO DIOVANI DA ROCHA que visualizou o exame e constatou que realmente havia um objeto estranho na região pélvica de NAIARA. Alega a depoente que no momento em que NAIARA foi informada que iria ser encaminhada junto ao hospital para verificação do referido objeto, ela (NAIARA) confessou que havia drogas introduzidas na vagina dela e em local apropriado, acompanhada pela depoente, retirou um invólucro embrorachado contendo substância análoga a cocaína e porção análoga a maconha. Novamente indagada, NAIARA disse que recebeu tal objeto na entrada da penitenciária de uma mulher desconhecida, não informando maiores detalhes, e iria entrega-lo quando estivesse dentro do presídio para outra visitante, negando que tal objeto seria entregue ao seu companheiro de nome ROBSON que cumpre pena no local. Alega a depoente que tem conhecimento que NAIARA esta incluída como companheira no rol de visitantes do sentenciado ROBSON RODRIGUES BARBOSA (RG 51.562.296-5 SSP/SP) que cumpre pena no local por vários crimes, dentre eles por tráfico de drogas. Foi acionada a polícia militar que conduziu NAIARA junto ao plantão policial, não sendo necessário o uso de algemas.

Em depoimento no juízo, a testemunha Márcio Diovani da Rocha, relatou que na época do fato, estava trabalhando no setor de portaria e que, a ré foi passada no aparelho scanner, no qual apresentou uma imagem diferente, das normal apresentas anteriormente nas passagens dela, e indagada a ré, negou ter algo de diferente nela ou em suas vestes, porém logo em seguida, a ré confessou que havia, retirou então o invólucro, e entregou para a funcionária, Alessandra. Ainda disse que no invólucro continha uma substância, de cor esverdeada, constatado depois que se tratava de maconha e que a ré não mencionou para quem seria a entrega da substância, e como ela era visitante do réu Robson, presumiu-se que era para ele, então como responsável, o réu foi intimado. Para o Dr. Promotor de Justiça, concluiu respondendo que não tem contato com o setor, que poderia ter conversado com o réu. Em interrogatório no juízo, a ré Naiara Souza Lima, disse que no dia do fato, foi até a Penitenciária, para informar o réu Robson que não iria mais visita-lo, por

problemas financeiros, quando encontrou uma moça na frente da Penitenciária que ofereceu dinheiro para entregar a maconha para uma pessoa de dentro, que iria encontra-la para receber a substância, e a ré acabou aceitando. Finalizou o interrogatório dizendo que não tem antecedentes, e que o réu Robson não sabia a respeito da droga.

Em interrogatório no juízo, o réu Robson Rodrigues Barbosa, disse que não tinha conhecimento da droga que estava com a ré Naiara.

Pois bem.

Em que pese a tese sustentada pelo nobre Dr. Defensor, a pretensão deduzida pelo Ministério Público comporta parcial acolhimento. Isso porque, ao cabo da instrução criminal, restou amplamente demonstrada a responsabilidade da acusada NAIARA SOUZA LIMA, pela prática do delito narrado na denúncia. Nesse sentido é firme e segura toda a prova deduzida, notadamente em Juízo, sob o crivo do contraditório. Tanto na fase policial, como em Juízo, a testemunha Márcio Diovani da Rocha, agente penitenciário, cuidou de detalhar os fatos ocorridos envolvendo a denunciada Naiara Souza Lima, indicando de forma segura o envolvimento da acusada com o tráfico de drogas. Declarou em Juízo que na data dos fatos estava na portaria onde exerce o cargo de diretor, momento em que a funcionária de nome Alessandra Dos Santos Martins informou que ao submeter a visitante de nome NAIARA SOUZA LIMA ao equipamento "scanner corporal", verificou que havia um objeto estranho na região pélvica dela. O depoente visualizou o exame e constatou que realmente havia um objeto estranho na região pélvica de NAIARA, sendo que indagada, negou estar na posse de qualquer objeto, e quando ela foi informada de que seria encaminhada ao Hospital para verificação do objeto, ela acabou confessando que havia drogas introduzidas na vagina dela e em local apropriado, acompanhada pela funcionária Alessandra, retirou um invólucro emborrachado contendo substância análoga a cocaína e porção análoga a maconha. Indagada, NAIARA informou que havia recebido o objeto de uma mulher desconhecida, na frente da penitenciária e o entregaria a outra visitante quando estivesse no interior do local, negando que as drogas eram para seu companheiro ROBSON que não tinha conhecimento.

A testemunha Alessandra dos Santos Martins, agente penitenciário, em sede policial, disse que no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 13:40, estava acompanhando a entrada de visitas junto ao equipamento "scaner corporal" e no momento em que a ré foi submetida ao exame, verificou que havia um objeto estanho na região pélvica dela. Que a princípio a ré negou que estava com algum objeto, mas posteriormente ao ser informada de que ela seria encaminhada junto ao hospital para verificação do referido objeto, Naiara confessou que havia drogas introduzidas na sua vagina. Que Naiara disse que recebeu tal objeto na entrada da penitenciária de uma mulher desconhecida e entregaria para outra visitante quando estivesse dentro do presídio. Que nego que tal objeto seria entregue ao seu companheiro Robson, que cumpria pena no local.

Nesse compasso, os depoimentos dos agentes penitenciários, não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra qualquer motivo suficientemente forte para que tais agentes da lei incriminassem a ré de forma gratuita.

E, como se sabe, o depoimento vale não pela condição dos depoentes, mas pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, seus testemunhos são harmônicos e coerentes entre si e estão em plena consonância com as demais provas dos autos, não havendo motivo para desprezá-los apenas por se tratarem de agentes públicos.

Além disso, a ré Naiara Souza Lima confessou em Juízo, que havia recebido o objeto contendo as drogas de uma pessoa desconhecida do sexo feminino quando estava defronte a penitenciária e o entregaria a outra visitante quando estivesse no interior do local, negando que as drogas eram para seu companheiro Robson que não tinha conhecimento.

Cumprir registrar que para a caracterização do delito em tela não se exige que o agente tenha atingido a finalidade lucrativa, tampouco que tenha praticado a conduta de venda e/ou entrega do entorpecente a usuários.

Isso porque o crime em tela é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, da Lei nº

11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento.

In casu, restou devidamente demonstrado que a ré trazia consigo, para fins de tráfico, o entorpecente apreendido.

Outrossim, menos ainda de prosperar eventual tese de estado de necessidade. É absolutamente inaceitável considerar que circunstâncias de dificuldade financeira sejam aptas a autorizar condutas criminosas, sob pena de desencadear uma alarmante situação de insegurança jurídica e estremer o convívio social, principalmente em localidades onde há concentração de pobreza.

Ademais, o tráfico de entorpecentes engendra infortúnios à população, de maneira geral, e ao Estado, vez que a distribuição de drogas afeta não só a vida do viciado e o convívio social, causando danos muitas vezes irreversíveis, como também o próprio Estado, em virtude dos prejuízos acarretados à saúde pública, bem penal tutelado pelo tipo.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico de drogas. 16,07g de cocaína. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. 2. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais, que se mostram coerentes e harmônicos. 3. Quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, apreensão do dinheiro, indicam o intuito de mercancia. Impossibilidade de desclassificação para a infração do artigo 28, da Lei 11.343/06. 4. Inexigibilidade de conduta diversa. Alegações atinentes às dificuldades financeiras do réu para satisfação das necessidades vitais próprias e de sua família não foram comprovadas pela Defesa, ônus imposto por expressa previsão no artigo 156 do CPP. Situação de dificuldades pelas quais a Defesa alega que o réu passava deve ser resolvida por meios idôneos. 5. Reprimenda reduzida. Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11/343/06 na fração máxima de dois terços. Pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa, no mínimo legal. 6. Fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", tendo em vista a quantidade de pena fixada e o tempo de prisão cautelar. 7. Conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e na prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo. Recurso parcialmente provido" (TJSP; Apelação 0045313-74.2012.8.26.0224; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2014; Data de Registro: 22/01/2015). "APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...) 4. A existência do tipo penal reflete a implícita reprovação da sociedade à conduta desvalorada pela lei, no caso, o tráfico de drogas, que tem como bem jurídico tutelado a saúde pública. Presume-se, portanto, que o cidadão deve agir de forma diversa dos inúmeros verbos elencados no preceito primário do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. E o ônus de provar a inexigibilidade de conduta diversa, apta a afastar a reprovação que implicitamente compõe o tipo, é, indiscutivelmente, da ré. 5. Não se acolhe a tese da defesa no sentido de aplicação das chamadas "teoria da co-culpabilidade" e da "culpabilidade funcional", teorias modernistas, que se tenta inserir no Direito Penal brasileiro, fundadas no sistema funcionalista do crime, na sua vertente racional-teleológica, também conhecida como "funcionalismo moderado". Tratam-se de teorias extremamente garantistas, que visam mais a beneficiar, e mesmo fomentar, a prática de novos crimes, não impingindo as devidas punições aos agentes criminosos, como forma de repelir novas práticas delitivas. Desta feita, não se pode conferir validade à pobreza, baixa escolaridade ou descaso do Estado para se justificar e permitir a prática de condutas penalmente tipificadas (...)" (TJSP;

Apelação 0003035-82.2014.8.26.0161; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Diadema - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2015).

Não há que se falar em atipicidade da conduta por crime impossível ou tentativa, em razão de o tráfico de drogas ter se consumado no instante em que a ré recebeu e trazia consigo os entorpecentes para o consumo alheio (crime de ação múltipla e formal), além de o meio utilizado, levar drogas em partes íntimas para o presídio em dias de visita, ser absolutamente eficaz e conhecido para a prática do delito. Do contrário, não haveria a entrada de entorpecentes em estabelecimento prisionais, fato conhecido por todos.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.IMPOSSIBILIDADE. DELITO UNISSUBSISTENTE. REVISTA ÍNTIMA.LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte em relação à conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 2. Não houve nenhuma contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade no julgado proferido pela Corte de origem, de modo a gerar o pretendido reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o Tribunal a quo efetivamente externou as razões pelas quais entendeu configurada a apontada nulidade arguida pela defesa (relativa à ordem do interrogatório) e considerou devida a absolvição da acusada. 3. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível, por isso mesmo, a sua ocorrência na modalidade tentada. 4. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes. 5. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "trazer consigo" ou "transportar". Vale dizer, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas (no caso, 143,7 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inviável, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime impossível. 6. Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos, drogas, aparelhos celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza o ingresso de tais objetos no presídio. 7. Não obstante a acusada tivesse o direito de se recusar ser revista intimamente, submeteu-se, de maneira voluntária, ao procedimento adotado no estabelecimento prisional, que resultou na localização, no interior de sua vagina, de 143,7 g de maconha, acondicionados dentro de um preservativo, os quais seriam entregues a seu companheiro, que estava preso no local. Assim, não houve ato ofensivo à honra da acusada, tampouco dano à sua integridade física ou moral. 8. As pessoas que se dirigem ao presídio sabem, previamente, que podem ser submetidas à revista pessoal e minuciosa. Trata-se. tal procedimento (quando realizado com estrita observância a procedimento legal e com respeito aos princípios e às garantias constitucionais), de legítimo exercício do poder de polícia do Estado, de cunho preventivo, o qual objetiva garantir a segurança social e os interesses públicos. 9. Caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo, tal como ocorreu na espécie dos autos. Precedentes. 10. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em

3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (lex mitior), já que assegura maior efetividade a princípios constitucionais, notadamente aos do contraditório e da ampla defesa. 11. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica dos feitos já sentenciados (CF, art. 5º, XXXVI), houve modulação dos efeitos da decisão: estabeleceu que essa orientação somente deve ser aplicada aos processos cuja instrução ainda não se haja encerrada. 12. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator" 2 Resp 1523735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018."TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES RECURSO DA ACUSAÇÃO PRETENDIDA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA DOS RÉUS LEANDRO E DOUGLAS PELA APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS NÃO ACOLHIMENTO QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA NÃO SE MOSTRA EXACERBADA A PONTO DE IMPEDIR O REDUTOR MÁXIMO A TENTATIVA DE LEVAR DROGAS PARA DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL JÁ FOI CONSIDERADA NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC.III, DA LEI DE DROGAS INVIÁVEL SUA UTILIZAÇÃO PARA MODULAR O REDUTOR, SOB PENA DE BIS IN IDEM - RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DAS DEFESAS DOS RÉUS ADILSON E DIEGO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS PENAS E REGIME INICIAL FECHADO MANTIDOS RECURSOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS LEANDRO E DOUGLAS PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL NÃO ACOLHIMENTO CRIME FORMAL - NÃO DEMONSTRADA, ADEMAIS, A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO UTILIZADO PARA EFETIVAR A INTRODUÇÃO DOS ENTORPECENTES NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL CRIME, ADEMAIS, CONSUMADO ANTES MESMO DE TENTAR INTRODUIR A DROGA NO PRESÍDIO PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS CONFISSÃO NÃO POSSIBILITA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO COL. STJ INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI DE DROGAS, QUANTO AO RÉU DOUGLAS, QUE ADQUIRIU O ENTORPECENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO REGIME INICIAL MITIGADO PARA O ABERTO CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO TJSP; Apelação Criminal 0002143-95.2017.8.26.0638; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021.

Portanto, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a procedência da ação, com condenação da ré NAIARA SOUZA LIMA, é a medida que se impõe.

Quanto ao réu ROBSON RODRIGUES BARBOSA, em que pese a tese sustentada pelo ilustre Dr. Promotor de Justiça, não há nos autos prova idônea acerca da autoria.

As testemunhas ouvidas nos autos, não dão conta de que o réu Robson Rodrigues Barbosa tinha conhecimento de que sua companheira, a ré Naiara Souza Lima trazia consigo entorpecentes, quando foi visitá-lo no presídio.

Salientando-se que a própria ré Naiara, em seu depoimento em Juízo, afirmou que Robson não sabia que ela teria tentado entrar no presídio com drogas, mesmo porque, conforme ela mesma declarou só conheceu a mulher que lhe entregou o objeto contendo as drogas, quando estava defronte a penitenciária, momentos antes de tentar ingressar no local.

Por fim, réu Robson Rodrigues Barbosa, declarou em Juízo que não teve envolvimento com os fatos tratados nestes autos, nem conhecimento acerca da tentativa de Naiara Souza Lima entrar no presídio na posse das drogas.

Ora, ante a prova colhida em Juízo é forçoso concluir pela absolvição do acusado Robson Rodrigues Barbosa, ante a escassez probatória. Salienta-se que apesar de devidamente comprovada a materialidade do delito, a autoria encontra-se calcada unicamente em presunções, com o que não se compadece o Direito Penal para a deflagração de uma condenação.

Ademais, como não é possível um édito condenatório baseado apenas em indícios ou suposições, a absolvição do acusado Robson Rodrigues Barbosa é de rigor. Nesse

ponto, cumpre salientar que, na seara do processo criminal, os fatos devem ser plenamente comprovados, não bastando a existência de mera possibilidade acerca da autoria e materialidade. Quando o Estado não prova estreme de dúvidas a autoria do fato criminoso, a presunção de inocência que milita em favor do réu deve prevalecer.

Não é novidade que “se o Juiz não possui provas sólidas para formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição” (Nucci, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 689). Entendo ser este o caso dos autos.

Com efeito, a sentença criminal exige, para sua procedência, um mínimo de comprovação segura da autoria do delito. No particular, as provas não são suficientes para sustentar o édito condenatório, razão pela qual a absolvição do acusado se impõe.

Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal.

O crime de tráfico é apenado com 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, por ser primária e não vislumbrar circunstâncias que justifiquem reprimendas maiores, fixo a pena-base no piso, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de fixação de pena, ausentes agravantes a serem consideradas.

Presente a atenuante da confissão. Contudo, como a pena já está no piso, deixo de aplicá-la (Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Na terceira fase, há causa de aumento de pena, nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, assim exaspero a pena em 1/6 fixando-a em 05 (cinco anos) e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Entretanto, ante a primariedade da ré, a ausência de antecedentes criminais e a não vinculação à organização criminosa, aplico a regra contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando a reprimenda em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cada qual no mínimo legal, valor que deverá ser atualizado monetariamente até o efetivo pagamento, de acordo com o artigo 49, caput, e § 2º c/c o artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Pela inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

Presentes os requisitos do artigo 44, § 3º do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em: a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, em local e condições indicados pela Central de Penas e Medidas Alternativas desta Comarca; b) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA (artigo 43, VI do Código Penal), pelo que deverá a ré se manter recolhida em seu domicílio, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída.

No tocante ao regime da pena, considerando a primariedade da ré, bem como que as circunstâncias judiciais são favoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos dos artigos 33, § 2º e 3º, c/c 59, ambos do Código Penal. Face à substituição da pena privativa de liberdade, incabível se mostra a suspensão de sua execução (artigo 77, III, do Código Penal).

Anoto, por fim, que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada no presente julgamento (artigo 315, § 2º do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão condenatória postulada na denúncia para, dando-o como incurso nos artigos 33, § 4 e 40, III, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, CONDENAR a acusada NAIARA SOUZA LIMA, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, SUBSTITUÍDA por duas penas restritivas de direito, consistentes em



a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, em local e condições indicados pela Central de Penas e Medidas Alternativas desta Comarca; b) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA (artigo 43, VI do Código Penal), pelo que deverá o réu se manter recolhido em seu domicílio, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e ABSOLVO o réu ROBSON RODRIGUES BARBOSA, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi irrogada com incurso nos artigos 33, caput, e 40, III, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Condeno a ré Naiara Souza Lima ao pagamento das custas processuais, observada a concessão da justiça gratuita.

Por fim, considerando-se que a ré se encontra em liberdade e que foi condenada a cumprimento de pena em regime aberto, substituída por restritivas de direito, deverá assim permanecer caso deseje recorrer desta decisão.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se guia de execução e o que mais que for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

P.I.C.

Marília, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA